MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Filosofia do Direito

Os autores e as ideias que a FGV mais cobra: dos clássicos e contratualistas ao positivismo de Kelsen e Hart, Dworkin, Alexy, Rawls, Habermas e os críticos do poder.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Filosofia trazem um trecho ou uma situação e pedem que você identifique o autor ou o conceito. Não é preciso ler as obras: basta associar cada autor às suas 2 ou 3 ideias centrais, que é exatamente o que esta sinopse organiza.

2	1	25	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	autores organizados por ideia-chave	seções com quadros-resumo

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Filosofia do Direito na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Antiguidade e Idade Média
2 Contratualistas
3 Kant e Hegel
4 Escolas do século XIX
5 Positivismo jurídico: Kelsen, Hart, Bobbio e Ross
6 Pós-positivismo: Dworkin, Alexy e Radbruch
7 Justiça, democracia e poder
8 Quadro final: autor e ideia-chave

1 Antiguidade e Idade Média

Aristóteles

- **Justiça como virtude** do meio-termo e como igualdade.

- **Justiça distributiva:** distribuição de honras e bens segundo o mérito de cada um. É uma igualdade **proporcional** (geométrica): tratar desigualmente os desiguais.
- **Justiça corretiva** (comutativa): nas relações entre particulares, restabelece a igualdade aritmética rompida por um contrato ou um dano, sem considerar quem são as partes.
- **Equidade (epieikeia):** corretivo da lei, que, por ser geral, não alcança todas as particularidades do caso concreto. A equidade é a justiça do caso concreto.
- O ser humano é um **animal político** (zoon politikon): só se realiza plenamente na pólis.

Platão

Em *A República*, a justiça é a harmonia da cidade e da alma: cada parte cumpre a sua função. A cidade ideal deve ser governada pelos filósofos, que conhecem as Ideias (mundo inteligível). O **mito da caverna** ilustra a passagem da ignorância (sombras) ao conhecimento.

Tomás de Aquino

- Distingue quatro leis: **eterna** (a razão divina que governa o universo), **natural** (a participação da criatura racional na lei eterna), **humana** (positiva, derivada da lei natural) e **divina** (revelada nas Escrituras).
- A lei humana que contraria a lei natural não é lei, mas corrupção da lei: **lei injusta não obriga em consciência**.
- A lei é uma ordenação da razão para o **bem comum**, promulgada por quem tem o cuidado da comunidade.

> **PARA MEMORIZAR**
>
> O **jusnaturalismo** sustenta que existe um direito anterior e superior ao direito posto pelo Estado (cosmológico na Grécia, teológico em Tomás de Aquino, racional nos modernos). O **positivismo** afirma que o direito é apenas o direito posto, válido por critérios formais, separado da moral.

2 Contratualistas

Autor	Estado de natureza	Contrato social	Ideia que cai
Hobbes Leviatã, 1651	Guerra de **todos contra todos**; a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. "O homem é o lobo do homem".	Os indivíduos transferem todos os seus direitos ao soberano em troca de **segurança** e paz.	Soberano **absoluto** (o Leviatã). Não há direito de resistência, salvo para preservar a própria vida.
Locke Segundo Tratado, 1689	Estado de liberdade e igualdade, regido pela lei natural, mas sem juiz imparcial para resolver conflitos.	Os indivíduos consentem em formar o governo para proteger seus **direitos naturais**: vida, liberdade e **propriedade**.	Governo limitado e separação de poderes. Se o governo viola os direitos naturais, o povo tem **direito de resistência**. Pai do liberalismo.
Rousseau Do Contrato Social, 1762	O homem nasce bom (o "bom selvagem"); é a sociedade, com a propriedade privada, que o corrompe.	Cada um se submete à **vontade geral**, que visa ao bem comum e não se confunde com a soma das vontades particulares (vontade de todos).	**Soberania popular**, inalienável e indivisível. A lei é expressão da vontade geral. Democracia direta.

- **Montesquieu** (*O Espírito das Leis*, 1748): formulou a **separação dos poderes** em Legislativo, Executivo e Judiciário, para que "o poder freie o poder". O juiz seria apenas a "boca que pronuncia as palavras da lei", ideia associada à Escola da Exegese.

> **COMO CAI**
>
> Um texto afirma que, sem um poder comum que mantenha todos em respeito, os homens vivem em condição de guerra, e que por isso transferem seus direitos a um soberano. **De que autor é a ideia?**
>
> Thomas Hobbes. A guerra de todos contra todos e a transferência de direitos ao soberano absoluto (o Leviatã) em troca de segurança são marcas do seu pensamento.

3 Kant e Hegel

Immanuel Kant

- **Imperativo categórico:** age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma **lei universal**. É incondicionado, ao contrário do imperativo hipotético (condicionado a um fim: "se queres X, faze Y").
- **Dignidade humana:** age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre como **fim** e nunca simplesmente como **meio**. No reino dos fins, as coisas têm **preço**; as pessoas têm **dignidade**.
- **Autonomia:** a vontade é livre quando dá a si mesma a lei moral (autonomia), e não quando segue impulsos ou ordens externas (heteronomia).
- **Direito × moral:** a moral diz respeito à liberdade **interna** e à intenção (agir por dever); o direito, à liberdade **externa** e à conformidade exterior da conduta, admitindo coação. O direito é o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio do outro segundo uma lei universal de liberdade.

Hegel

Concebe a história como desenvolvimento dialético do Espírito (tese, antítese, síntese) rumo à liberdade. O **Estado** é a realização da ideia ética, momento superior à família e à sociedade civil. "O que é racional é real, e o que é real é racional."

Marx

O direito integra a **superestrutura**, determinada pela base econômica (infraestrutura, relações de produção). O direito burguês é instrumento de dominação de classe que oculta a exploração sob a forma da igualdade formal. Com o fim das classes, o Estado e o direito tenderiam a desaparecer.

4 Escolas do século XIX

Escola ou autor	Ideia central
Escola da Exegese (França)	Culto ao Código Napoleônico (1804). O direito se reduz à lei; o juiz deve apenas aplicá-la, buscando a **vontade do legislador**. Interpretação literal e gramatical.
Escola Histórica (Savigny, Alemanha)	O direito nasce do **espírito do povo** (Volksgeist), como a língua, e se forma pelo costume. Savigny opôs-se à codificação apressada do direito alemão.
Ihering	Em *A luta pelo direito*, sustenta que o direito é conquistado por uma luta incessante, e que defender o próprio direito é um dever do titular para consigo e para com a sociedade. Desenvolveu a jurisprudência dos interesses: o fim é o criador de todo o direito.
Utilitarismo (Bentham, Mill)	A ação correta é a que produz a **maior felicidade para o maior número** de pessoas. Bentham imaginou o **panóptico**, prisão em que todos são vigiados sem saber quando. Mill defendeu o princípio do dano: o único fim que justifica restringir a liberdade de alguém é impedir dano a outros.
Miguel Reale (Brasil, século XX)	**Teoria tridimensional do direito:** o direito é a integração dinâmica de **fato, valor e norma**. A norma resulta da tensão entre um fato social e um valor.

5 Positivismo jurídico: Kelsen, Hart, Bobbio e Ross

Hans Kelsen (Teoria Pura do Direito)

- Busca uma ciência do direito **pura**, livre de elementos morais, políticos, sociológicos e psicológicos. Separa o mundo do **ser** (causalidade) e o do **dever-ser** (imputação).
- O ordenamento é uma estrutura escalonada (a pirâmide normativa): cada norma retira sua validade de uma norma superior.
- No topo está a **norma fundamental** (Grundnorm), que **não é posta, mas pressuposta**: uma hipótese lógica que fundamenta a validade da Constituição ("deve-se obedecer à Constituição").
- **Validade** é a existência específica da norma, independente de seu conteúdo moral. A eficácia global do ordenamento é condição da validade.
- **Interpretação:** a norma é uma **moldura** com várias possibilidades de aplicação; a escolha do juiz dentro dela é um ato de **vontade**, e não apenas de conhecimento.

Herbert Hart (O Conceito de Direito)

- O direito é a união de **regras primárias** (impõem deveres, dizem o que fazer) e **regras secundárias** (regras sobre regras).
- As regras secundárias são: de **reconhecimento** (identificam quais normas pertencem ao sistema, a mais importante), de **alteração** (criam e modificam regras) e de **julgamento** (atribuem competência para decidir violações).
- A linguagem jurídica tem **textura aberta**: há casos difíceis em que a regra não dá resposta clara. Nesses casos, o juiz tem **discricionariedade** e cria direito.
- Distingue o **ponto de vista interno** (de quem aceita a regra como padrão de conduta) e o externo (de quem apenas observa regularidades).

Norberto Bobbio

- **Antinomias** (normas incompatíveis) resolvem-se por três critérios: **hierárquico** (norma superior prevalece), **cronológico** (posterior revoga anterior) e da **especialidade** (especial prevalece sobre geral). Quando os critérios conflitam, há antinomia de segundo grau.
- O ordenamento busca **unidade, coerência e completude**. As **lacunas** são colmatadas por analogia, costumes e princípios gerais.
- Em *A Era dos Direitos*, afirma que o problema fundamental dos direitos humanos hoje não é tanto **justificá-los**, mas **protegê-los**.

Alf Ross e o realismo jurídico

O direito vigente é o conjunto de normas que **os tribunais efetivamente aplicam**. Afirmar que uma norma é direito é fazer uma **previsão** sobre como os juízes decidirão. No realismo norte-americano, Oliver Holmes definiu o direito como as profecias do que os tribunais farão de fato.

6 Pós-positivismo: Dworkin, Alexy e Radbruch

Ronald Dworkin

- Critica o positivismo de Hart: o direito não é composto só de **regras**, mas também de **princípios**.
- **Regras** aplicam-se à maneira do **tudo ou nada**: se válidas e aplicáveis, determinam a decisão. **Princípios** têm uma dimensão de **peso** e importância, e, em caso de colisão, um prevalece sem que o outro deixe de ser válido.
- Nos casos difíceis, o juiz não tem discricionariedade forte: deve buscar a **única resposta correta**, à luz dos princípios.
- **Juiz Hércules:** juiz ideal, de capacidade sobre-humana, capaz de reconstruir todo o direito de forma coerente.
- **Direito como integridade** e **romance em cadeia**: o juiz é como um escritor que recebe os capítulos anteriores de um romance e deve escrever o próximo de forma coerente com a história.

Robert Alexy

- **Princípios são mandados de otimização:** ordenam que algo seja realizado na **maior medida possível**, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. **Regras** são mandados definitivos: ou se cumprem, ou não.
- Colisões entre princípios resolvem-se por **ponderação**, segundo a máxima da **proporcionalidade**, composta por três submáximas: **adequação** (o meio fomenta o fim?), **necessidade** (há meio menos gravoso igualmente eficaz?) e **proporcionalidade em sentido estrito** (o benefício justifica a restrição?).
- Conflitos entre regras resolvem-se pela declaração de invalidade de uma delas ou pela introdução de uma cláusula de exceção.

Gustav Radbruch

Após o nazismo, formulou a **fórmula de Radbruch**: o direito positivo deve prevalecer mesmo quando injusto, salvo quando a contradição com a justiça atingir um grau tão **insuportável** que a lei, como "direito injusto", deva ceder à justiça. Em síntese: a **injustiça extrema não é direito**.

> **ATENÇÃO**
>
> **Dworkin**: princípios têm dimensão de peso; regras, tudo ou nada; única resposta correta. **Alexy**: princípios são mandados de otimização; ponderação e proporcionalidade. **Hart**: regras primárias e secundárias; textura aberta e discricionariedade. A FGV troca os três.

7 Justiça, democracia e poder

John Rawls (Uma Teoria da Justiça, 1971)

- Justiça como **equidade** (fairness). Os princípios de justiça seriam escolhidos numa **posição original**, sob o **véu da ignorância**: ninguém sabe qual será seu lugar na sociedade, sua classe, seus talentos ou sua concepção de bem.
- **1º princípio (liberdade):** cada pessoa tem direito igual ao mais amplo sistema de liberdades básicas compatível com um sistema semelhante para todos.
- **2º princípio:** as desigualdades sociais e econômicas devem estar vinculadas a cargos abertos a todos, em **igualdade equitativa de oportunidades**, e trazer o maior benefício possível aos **menos favorecidos** (princípio da diferença).
- O primeiro princípio tem **prioridade** sobre o segundo.

Jürgen Habermas

Teoria do **agir comunicativo**: a legitimidade das normas decorre de um processo discursivo em que todos os afetados possam participar livremente, em condições de igualdade, guiados pela força do melhor argumento. Defende a **democracia deliberativa** e a cooriginariedade entre autonomia pública (soberania popular) e autonomia privada (direitos humanos).

Max Weber

Distingue três tipos puros de **dominação legítima**: **legal-racional** (baseada em regras impessoais e na burocracia), **tradicional** (baseada na santidade dos costumes) e **carismática** (baseada nas qualidades extraordinárias do líder). O Estado moderno detém o monopólio do uso legítimo da força.

Michel Foucault

- Em *Vigiar e Punir*, analisa a passagem do suplício público para a prisão e o surgimento do **poder disciplinar**, que produz corpos dóceis e úteis por meio da vigilância, da normalização e do exame. O panóptico de Bentham é seu modelo.
- O poder não é apenas repressivo nem está só no Estado: é **relacional**, difuso e produtivo. Desenvolveu ainda o conceito de **biopoder** (gestão da vida das populações).

Hannah Arendt

- **Banalidade do mal:** ao acompanhar o julgamento de Eichmann, concluiu que grandes crimes podem ser cometidos por pessoas comuns, que obedecem sem pensar, e não necessariamente por monstros.
- **Direito a ter direitos:** a perda da cidadania (os apátridas) mostrou que os direitos humanos dependem do pertencimento a uma comunidade política organizada.

Niklas Luhmann

O direito é um **sistema autopoiético**: social, operacionalmente fechado e cognitivamente aberto, que se reproduz a partir de seus próprios elementos, segundo o código binário lícito/ilícito.

8 Quadro final: autor e ideia-chave

Autor	Palavra-chave na questão
Aristóteles	Justiça distributiva e corretiva; equidade; animal político
Tomás de Aquino	Lei eterna, natural, humana e divina; lei injusta não é lei
Hobbes	Guerra de todos contra todos; Leviatã; segurança
Locke	Vida, liberdade e propriedade; direito de resistência
Rousseau	Vontade geral; soberania popular; bom selvagem
Montesquieu	Separação dos poderes; juiz boca da lei
Kant	Imperativo categórico; pessoa como fim; dignidade × preço; autonomia
Marx	Direito como superestrutura; luta de classes
Savigny	Espírito do povo; Escola Histórica
Ihering	Luta pelo direito; jurisprudência dos interesses
Bentham e Mill	Maior felicidade para o maior número; panóptico; princípio do dano
Reale	Fato, valor e norma (tridimensional)
Kelsen	Teoria pura; norma fundamental pressuposta; pirâmide; moldura
Hart	Regras primárias e secundárias; regra de reconhecimento; textura aberta
Bobbio	Antinomias (hierárquico, cronológico, especialidade); proteger os direitos
Ross e Holmes	Direito como previsão do que os tribunais decidirão
Dworkin	Princípios com peso; única resposta correta; juiz Hércules; romance em cadeia
Alexy	Mandados de otimização; ponderação; proporcionalidade
Radbruch	Injustiça extrema não é direito
Rawls	Véu da ignorância; posição original; princípio da diferença
Habermas	Agir comunicativo; democracia deliberativa
Weber	Dominação legal, tradicional e carismática
Foucault	Poder disciplinar; Vigiar e Punir; biopoder
Arendt	Banalidade do mal; direito a ter direitos
Luhmann	Sistema autopoiético; código lícito/ilícito

Checklist da véspera

- [ ] Sei diferenciar jusnaturalismo e positivismo.

- [ ] Sei o estado de natureza e o contrato social de Hobbes, Locke e Rousseau.
- [ ] Sei as formulações do imperativo categórico de Kant.
- [ ] Sei a norma fundamental de Kelsen e as regras secundárias de Hart.
- [ ] Sei a diferença entre Dworkin e Alexy sobre princípios.
- [ ] Sei os dois princípios de justiça de Rawls e o véu da ignorância.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB a partir das obras clássicas da filosofia do direito e da teoria do direito cobradas nas provas da FGV. Os resumos são interpretações didáticas das ideias centrais de cada autor. Confira sempre a redação atualizada da lei.